

1500954-98.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2008631/2022 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 22370645 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 163/22/250 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 2008631 - 50º D.P. ITAIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500954-98.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500954-98.2022.8.26.0228 - Ctrl. 0101/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2008631/2022 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 22370645 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 163/22/250 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 2008631 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO SILVA PEREIRA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

VISTOS.

LEANDRO SILVA PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, como narra a denúncia, em ocasião de calamidade pública, no dia 10 de janeiro de 2022, por volta das 09h10min, na Estrada Dom João Nery, nº 3551, Jardim Bartira, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 26 porções de Tetrahydrocannabinol (THC) na forma da substância popularmente conhecida como "maconha", com massa líquida total de 43,2 gramas; 101 porções de cocaína, com massa líquida total de 31,5 gramas; 25 porções de Tetrahydrocannabinol (THC) na forma da substância popularmente conhecida como

"maconha", com massa líquida total de 36,35 gramas; e 100 porções de cocaína, com massa líquida total de 23,3 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O denunciado foi notificado. Houve oferecimento de defesa preliminar. A denúncia foi recebida, seguiu-se citação. Em instrução, foram ouvidas testemunhas comuns. Seguiu-se aditamento da denúncia para o fim de dar o acusado por incurso no artigo 33, "caput", em c/c o artigo 40, inciso III, da Lei n. 11343/2006 que, após manifestação da Defesa, foi recebido.

Em instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns. Interrogado, o acusado fez-se confesso. Nos debates, o Ministério Público postulou a procedência da ação, enquanto a Defesa pugnou por absolvição, com teses subsidiárias em termos de apenamento.

Síntese do necessário.

Relato, DECIDO.

Denúncia PROCEDENTE em parte.

Segundo apurado, na data e local indicados na denúncia, guardas municipais, durante patrulhamento, avistaram o réu em atitude que consideraram suspeita, decidindo abordá-lo. Em revista pessoal, os agentes públicos encontraram em seu poder uma pequena bolsa dentro da qual estavam 101 porções de cocaína e 26 porções de maconha, além da quantia de R\$ 52,00 em dinheiro.

Ao ser indagado se havia mais drogas, LEANDRO apontou o local exato onde foram encontradas, enterradas, mais drogas, consistentes em 25 porções de maconha e 100 porções de cocaína. Em razão disso, foi preso em flagrante.

A materialidade restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão e laudo químico-toxicológico acostado aos autos, de forma a estabelecer perfeita correlação entre o material apreendido, aquele submetido à avaliação preliminar e, finalmente, o exame toxicológico.

Igualmente a autoria é certa.

O guarda municipal Guilherme Maurício Oliveira Gomes Santos disse que no dia dos fatos, ele e outro guarda estavam de patrulhamento, quando avistaram o réu em atitude suspeita, motivando sua abordagem, tendo em vista que ele, réu, estava no interior de um equipamento municipal, um parque. Um dos visitantes deste parque noticiou o consumo de entorpecentes naquele próprio municipal, motivo pelo qual foram até o ponto indicado. Em poder dele, réu, foi encontrada uma pequena bolsa, dentro da qual havia as porções de drogas e dinheiro. Ele ainda tentou empreender fuga pelos fundos do parque. Ao ser questionado se existiriam mais drogas, o próprio acusado apontou o ponto exato onde estavam enterradas outras porções de drogas, idênticas àquelas encontradas em busca pessoal junto ao acusado.

No mesmo sentido, em suma, o quanto narrado pelo guarda municipal Horácio dos Santos Lima Junior.

Interrogado, o réu fez-se confesso.

Foi o que se colheu da prova oral.

A prova amealhada basta para a condenação.

O réu foi flagrado por guardas municipais em poder de expressiva quantidade e variedade de drogas, a indicar a autoria e, ao mesmo tempo, a destinação ao

comércio espúrio.

Ademais, a prisão do acusado foi absolutamente lícita. Tráfico, como cediço, é crime permanente e, em tal condição, absolutamente legítima a atuação de guardas metropolitanos ou municipais na realização da prisão. Se qualquer do povo poderia fazê-lo, com muito mais acerto, e mesmo dever, é que os servidores públicos assim procedam.

Veja-se o entendimento da matéria pelo C. STJ:

RHC. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. APREENSÃO DE COISAS. LEGALIDADE. DELITO PERMANENTE.

1. A guarda municipal, a teor do disposto no § 8º, do art. 144, da Constituição Federal, tem como tarefa precípua a proteção do patrimônio do município, limitação que não exclui nem retira de seus integrantes a condição de agentes da autoridade, legitimados, dentro do princípio de auto defesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontra em flagrante delito, como de resto facultado a qualquer do povo pela norma do art. 301 do Código de Processo Penal.

2. Nestas circunstâncias, se a lei autoriza a prisão em flagrante, evidentemente que faculta - também - a apreensão de coisas, objeto do crime.

3. Apenas o auto de prisão em flagrante e o termo de apreensão serão lavrados pela autoridade policial.

4. Arguição de nulidade rejeitada, visto que os acusados, quando detidos, estavam em situação de flagrância, na prática do crime previsto no art. 12, da Lei nº

6.368/76 - modalidade guardar substância entorpecente.

5. RHC improvido.

(RHC 7.916/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/1998, DJ 09/11/1998, p. 175)

Não bastasse, como visto da prova, a prisão do acusado se deu, exatamente, porque estava na prática do tráfico de entorpecentes no interior de um parque municipal, equipamento público cuja fiscalização e preservação compete, exatamente, à Guarda Civil Metropolitana, a rigor do artigo 144, parágrafo 8º, da Constituição Federal.

A circunstância agravante relativamente à prática do ilícito no interior de um parque municipal também não vinga, a rigor do texto legal. Com efeito, o parque municipal não se enquadra em nenhum dos comandos do inciso III do artigo 40 da Lei de regência. A rigor, somente pode ser considerado um estabelecimento ou equipamento público, que não é, contudo, prisional, de ensino ou hospitalar. Tampouco é sede de qualquer entidade ou local de trabalho coletivo, mas sim equipamento de lazer e, finalmente, a locução "recinto" traduz a ideia de local fechado, que se mostra incompatível com a ideia de parque, amplo espaço aberto para convivência social.

Portanto, a denúncia procede parcialmente.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase da dosimetria, nos termos do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, a pena-base será fixada no piso, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mínimos.

Na segunda fase da dosimetria, cabível, ainda, a incidência do agravamento da pena em razão da calamidade pública, uma vez que o delito fora praticado em meio à pandemia ocasionada pelo COVID.

E, no ponto, descabe falar que a conduta em nada fora afetada, ou que ela nada afetou, o mundo fenomênico. Absolutamente. Primeiro porque, como cediço, situações

de calamidade pública trazem sempre a necessidade de readequação dos equipamentos públicos governamentais, direcionando-os ao combate, no caso, da pandemia. Isso significa diminuição de vigilância, maiores gastos com o atendimento das demandas urgentes e, por efeito direto, menor poder de polícia do Estado. Depois, porque todo prejuízo suportado pelo Estado, nestas excepcionais circunstâncias, representa maior gravame, diante da escassez de recursos decorrente da queda da atividade econômica, fato público e notório, a independer de prova.

Ademais, como se extrai da doutrina, “essa agravante genérica justifica-se pela insensibilidade moral do agente, que não observa os mais mezinhos postulados de fraternidade e de solidariedade humana e se aproveita de situações calamitosas ou de desgraça particular da vítima, que se encontra em posição de inferioridade, para praticar um crime”. Também, nesse sentido, o escólio de Rogério Sanches Cunha.

Assim, de forma alguma estamos diante de uma situação de responsabilidade penal objetiva.

Em virtude disso, agravo sua pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mínimos.

Na terceira etapa, aplicado o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo, reduzo a pena para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, mínimos.

Possível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, no caso dos autos.

Isso porque, considerando-se os fatores já enunciados do artigo 33, parágrafo quarto, da Lei n. 11343/2006, quando se cuida de agente primário, de bons antecedentes e não dedicado a atividades criminosas e, mais, cuja quantidade de droga apreendida não seja expressivamente grave, temos a hipótese de réu com menor potencial de ofensividade à coletividade.

A Lei de regência deixou ao critério do julgador a discricionariedade de individualizar a pena do acusado e, nesse sentido, evidente que quis o legislador conferir ao réu que se enquadre no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei Federal n. 11343/2006 um 'status' jurídico diferenciado. Por isso mesmo que, “diante da possibilidade de imposição de pena diminuída, evidente que tanto a fixação do regime inicialmente fechado, como a impossibilidade de conversão da sanção alternativa, podem se tornar medidas excessivas e desproporcionais em relação ao crime de tráfico. A determinação da decisão do Pleno do STF de não se poder tirar do juiz a atividade de individualizar concretamente a sanção penal de acordo com a culpabilidade pelo fato praticado, representa, no dizer de Eduardo Correia, a arte de julgar do juiz criminal. Aí, na verdade, se afinam todas as nuances e particulares sentidos dos fins das penas; aí há que lançar mão de todos os ensinamentos da criminologia e da política criminal; aí se apuram todas as infinitas gradações dos vários momentos em que se analisa o crime”.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu desta maneira:

“A jurisprudência desta Corte está alinhada no sentido do cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por outra, restritiva de direitos, nos crimes de tráfico de entorpecentes. Nesse sentido, o HC n. 93.857, Cezar Peluso, DJ 16.10.09 e o HC n. 99.888, de que fui relator, DJ 12.12.10. Ordem concedida para determinar a substituição da pena privativa de liberdade por outra, restritiva de direitos” (STF, 2ª Turma, HC 97.500, rel. Eros Grau, j. 25.05.2010)

No mesmo sentido, ainda junto ao C. STF:

EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. Tráfico de entorpecentes. Causa de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). Eleição do grau de redução. Motivação idônea para a redução em grau intermediário. Recurso não provido. Conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Possibilidade. Precedentes. Questão, todavia, não analisada pelas instâncias antecedentes. Ordem de habeas corpus concedida de ofício. 1. Encontra-se convenientemente motivada a eleição do grau de redução pela minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 2. Embora o paciente seja primário, a natureza da droga apreendida (42 pedras de crack) justificam a diminuição da pena em 1/3 (um terço). 3. Recurso não provido. 4. Impossibilidade de análise em sede recursal de temas não apreciados nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância. 5. A jurisprudência desta Suprema Corte admite a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, mesmo quando se trata do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Precedentes. Questão, todavia, não analisada pelas instâncias antecedentes. 6. Ordem de habeas corpus concedida de ofício. (RHC 109374, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/11/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 05-12-2011 PUBLIC 06-12-2011)

O Senado Federal, por sua vez, através da Resolução n. 05, de 15 de fevereiro de 2012, suspendeu a eficácia da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do parágrafo quarto do artigo 33 da Lei de regência, com fulcro no 'decisum' adotado no HC 97.256/RS. De outro ângulo, sabido e consabido (ou ao menos deveria sê-lo) que a opinião pessoal do julgador sobre a gravidade do delito (e nesse sentido compartilha-se do entendimento da enorme potencialidade lesiva do crime cometido, que mereceria, 'ad argumentandum tantum', melhor resposta repressiva do Estado) não pode importar no estabelecimento de situação prisional mais grave que aquela prevista em lei, porque tal postura, seja de primeiro ou segundo grau de jurisdição CONSTITUI AFRONTA AO ENTENDIMENTO DO C. STF. Finalmente, em processo originário desta 20ª Vara Criminal, em julgamento da Apelação Criminal n. 0088905-16.2009;9.26.0050, de igual maneira decidiu o TJSP.

Assim, presentes os pressupostos legais, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por aquela restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena corporal, nos termos do artigo 46, parágrafo terceiro, em entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução, segundo as aptidões do condenado, bem como na proibição de frequência a bares, boates, restaurantes e congêneres, no período noturno, pelo mesmo período, na forma do artigo 47, inciso IV, em combinação com o artigo 44, parágrafo segundo, parte final.

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o réu LEANDRO SILVA PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena corporal nos termos deste julgado, e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, mínimos, por incurso nas penas do artigo 33, caput e §4º, da Lei 11.343/06 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal.

Em vista da pena imposta, possível o recurso em liberdade. EXPEÇA-SE alvará de soltura.

Já juntado laudo químico-toxicológico definitivo, determino a incineração dos entorpecentes apreendidos.

Determino a perda do numerário em favor da FUNAD.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de maio de 2022.

RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA